

TEMA X



LEY 40/2.015, DE 1 DE OCTUBRE, DE RÉGIMEN JURÍDICO DEL SECTOR PÚBLICO: DISPOSICIONES GENERALES.

DE LOS ÓRGANOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ABSTENCIÓN Y RECUSACIÓN.

DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

ÍNDICE

0.- Introducción.	
1.- Disposiciones generales.	
1.1.- Objeto de la Ley. 1.2.- Ámbito subjetivo. 1.3.- Principios generales. 1.4.- Principios de la intervención de las Administraciones Públicas para el desarrollo de una actividad.	
2.- De los órganos de las Administraciones Públicas: Abstención y recusación.	
2.1.- Definición de los órganos de las Administraciones Públicas. 2.2.- La abstención. 2.3.- La recusación.	
3.- De la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.	
3.1.- Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. 3.2.- Responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas.	

O.- INTRODUCCIÓN.

El 26 de octubre de 2012 el Consejo de Ministros acordó la creación de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas con el mandato de realizar un **estudio integral dirigido a modernizar el sector público español**, dotarle de una mayor eficacia y eliminar las duplicidades que le afectaban y simplificar los procedimientos a través de los cuales los ciudadanos y las empresas se relacionan con la Administración.

El informe, que fue elevado al Consejo de Ministros el 21 de junio de 2013, formuló 218 propuestas basadas en el convencimiento de que una economía competitiva exige unas Administraciones Públicas eficientes, transparentes, ágiles y centradas en el servicio a los ciudadanos y las empresas. En la misma línea, el Programa nacional de reformas de España para 2014 establece la necesidad de **impulsar medidas para racionalizar la actuación administrativa, mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos y aumentar su productividad.**

Este convencimiento está inspirado en lo que dispone el propio **artículo 31.2 de la Constitución Española,** cuando establece que el gasto público realizará una **asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía.**

Como se señala en el Informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (en adelante CORA), la normativa reguladora de las Administraciones Públicas ha pasado por diferentes etapas. Tradicionalmente, las reglas reguladoras de los aspectos orgánicos del poder ejecutivo estaban separadas de las que disciplinaban los procedimientos. Esta separación terminó con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que unificó en un solo instrumento estas materias.

La evolución normativa posterior se ha caracterizado por la profusión de leyes, reales decretos y demás disposiciones de inferior rango, que han completado la columna vertebral del derecho administrativo. De este modo, nos encontramos en el momento actual normas que regulan aspectos orgánicos, como la Ley 6/1997, de 14 de abril, de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado; la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno y la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias estatales para la mejora de los servicios públicos; y otras que tratan aspectos tanto orgánicos como procedimentales de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre; o la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, por citar las más relevantes.

Resulta, por tanto evidente, la necesidad de dotar a nuestro sistema legal de un **derecho administrativo sistemático, coherente y ordenado,** de acuerdo con el proyecto general de mejora de la calidad normativa que inspira todo el informe aprobado por la CORA. En él se previó la elaboración de dos leyes: una, reguladora del procedimiento administrativo, que integraría las normas que rigen la relación de los ciudadanos con las Administraciones[1].

Otra, comprensiva del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, donde se incluirían las disposiciones que disciplinan el sector público institucional. Con ello, se aborda una reforma integral de la organización y funcionamiento de las Administraciones articulada en dos ejes fundamentales: la ordenación de las relaciones ad extra de las Administraciones con los ciudadanos y empresas, y la regulación ad intra del funcionamiento interno de cada Administración y de las relaciones entre ellas.

[1] Esta Ley es la Ley 39/2.015, que estudiamos en el Tema IX.

La presente Ley (**Ley 40/2.015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público**) responde al segundo de los ejes citados, y abarca, por un lado, la legislación básica sobre régimen jurídico administrativo, aplicable a todas las Administraciones Públicas; y por otro, el régimen jurídico específico de la Administración General del Estado, donde se incluye tanto la llamada Administración institucional, como la Administración periférica del Estado. Esta Ley contiene también la regulación sistemática de las relaciones internas entre las Administraciones, estableciendo los principios generales de actuación y las técnicas de relación entre los distintos sujetos públicos.

El Informe CORA recomienda reformar el ordenamiento jurídico administrativo no solo por razones de coherencia normativa y política legislativa. Las Administraciones Públicas, lejos de constituir un obstáculo para la vida de los ciudadanos y las empresas, deben facilitar la libertad individual y el desenvolvimiento de la iniciativa personal y empresarial. Para ello es imprescindible establecer un marco normativo que impida la creación de órganos o entidades innecesarios o redundantes, y asegure la eficacia y eficiencia de los entes públicos, ejerciendo sobre ellos una supervisión continua que permita evaluar el cumplimiento de los objetivos que justificaron su creación, y cuestionar su mantenimiento cuando aquellos se hayan agotado o exista otra forma más eficiente de alcanzarlos.

1.- DISPOSICIONES GENERALES.

En el **Título Preliminar de la Ley 40/2.015** se desarrollan:

- Las Disposiciones generales.
- Los principios de actuación.
- El funcionamiento del sector público.

1.1.- OBJETO DE LA LEY.

La presente Ley establece y regula:

- Las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas.
- Los principios del sistema de responsabilidad de las Administraciones Públicas y de la potestad sancionadora.
- La organización y funcionamiento de la Administración General del Estado y de su sector público institucional para el desarrollo de sus actividades.

1.2.- ÁMBITO SUBJETIVO.

La presente Ley se aplica al **sector público** que comprende:

a) La Administración General del Estado.

b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas.

c) Las Entidades que integran la Administración Local.

d) El sector público institucional.

El **sector público institucional** se integra por:

a) Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas.

b) Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas que quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley que específicamente se refieran a las mismas, en particular a los principios previstos en el artículo 3, y en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas.

c) Las Universidades públicas que se regirán por su normativa específica y supletoriamente por las previsiones de la presente Ley.

Tienen la consideración de Administraciones Públicas la **Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local, así como los organismos públicos y entidades de derecho público** previstos.

1.3.- PRINCIPIOS GENERALES.

Las Administraciones Públicas **sirven con objetividad los intereses generales** y **actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho.**

Deberán respetar en su actuación y relaciones los siguientes principios:

a) Servicio efectivo a los ciudadanos.

b) Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos.

c) Participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa.

d) Racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión.

e) Buena fe, confianza legítima y lealtad institucional.

f) Responsabilidad por la gestión pública.

g) Planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación de los resultados de las políticas públicas.

h) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados.

i) Economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales.

j) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.

k) Cooperación, colaboración y coordinación entre las Administraciones Públicas.

Las Administraciones Públicas se **relacionarán entre sí y con sus órganos, organismos públicos y entidades vinculados o dependientes a través de medios electrónicos**, que aseguren la interoperabilidad y seguridad de los sistemas y soluciones adoptadas por cada una de ellas, garantizarán la protección de los datos de carácter personal, y facilitarán preferentemente la prestación conjunta de servicios a los interesados.

Bajo la dirección del Gobierno de la Nación, de los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas y de los correspondientes de las Entidades Locales, la actuación de la Administración Pública respectiva se desarrolla para alcanzar los objetivos que establecen las leyes y el resto del ordenamiento jurídico.

Cada una de las Administraciones Públicas actúa para el cumplimiento de sus fines con **personalidad jurídica única.**

1.4.- PRINCIPIOS DE LA INTERVENCIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO DE UNA ACTIVIDAD.

Las Administraciones Públicas que, en el ejercicio de sus respectivas competencias, establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, deberán aplicar el **principio de proporcionalidad** y elegir la medida menos restrictiva, motivar su necesidad para la protección del interés público así como justificar su adecuación para lograr los fines que se persiguen, sin que en ningún caso se produzcan diferencias de trato discriminatorias. Asimismo, deberán evaluar periódicamente los efectos y resultados obtenidos.

Las Administraciones Públicas velarán por el cumplimiento de los requisitos previstos en la legislación que resulte aplicable, para lo cual podrán, en el ámbito de sus respectivas competencias y con los límites establecidos en la legislación de protección de datos de carácter personal, **comprobar, verificar, investigar e inspeccionar los hechos, actos, elementos, actividades, estimaciones y demás circunstancias que fueran necesarias.**

2.- DE LOS ÓRGANOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ABSTENCIÓN Y RECUSACIÓN.

2.1.- DEFINICIÓN DE LOS ÓRGANOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

Tendrán la consideración de **órganos administrativos** las **unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo**.

La **creación de cualquier órgano administrativo** exigirá, al menos, el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Determinación de su forma de integración en la Administración Pública de que se trate y su dependencia jerárquica.

b) Delimitación de sus funciones y competencias.

c) Dotación de los créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento.

Los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante **instrucciones y órdenes de servicio.**

2.2.- LA ABSTENCIÓN.

Las **autoridades y el personal al servicio de las Administraciones** en quienes se den algunas de las circunstancias señaladas en el apartado siguiente **se abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo comunicarán a su superior inmediato**, quien resolverá lo procedente.

Son **motivos de abstención** los siguientes:

a) Tener **interés personal en el asunto** de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.

b) Tener **un vínculo matrimonial** o situación de hecho asimilable y el **parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo,** con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato.

c) Tener **amistad íntima o enemistad manifiesta** con alguna de las personas mencionadas en el apartado anterior.

d) Haber intervenido como **perito o como testigo** en el procedimiento de que se trate.

e) Tener **relación de servicio con persona natural o jurídica** interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar.

Los órganos jerárquicamente superiores a quien se encuentre en alguna de las circunstancias señaladas en el punto anterior podrán ordenarle que se abstengan de toda intervención en el expediente.

La actuación de autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas en los que concurran motivos de abstención **no implicará, necesariamente, y en todo caso, la invalidez de los actos en que hayan intervenido.**

La no abstención en los casos en que concurra alguna de esas circunstancias dará lugar a la responsabilidad que proceda.

2.3.- LA RECUSACIÓN.

En los casos previstos en el artículo anterior, **podrá promoverse recusación por los interesados en cualquier momento de la tramitación del procedimiento.**

- La recusación **se planteará por escrito** en el que se expresará la causa o causas en que se funda.
- En el día siguiente el recusado manifestará a su inmediato superior si se da o no en él la causa alegada. En el primer caso, si el superior aprecia la concurrencia de la causa de recusación, acordará su sustitución acto seguido.
- Si el recusado niega la causa de recusación, el superior resolverá en el plazo de tres días, previos los informes y comprobaciones que considere oportunos.
- Contra las resoluciones adoptadas en esta materia no cabrá recurso, sin perjuicio de la posibilidad de alegar la recusación al interponer el recurso que proceda contra el acto que ponga fin al procedimiento.

3.- DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

3.1.- RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

3.1.1.- PRINCIPIOS DE LA RESPONSABILIDAD.

Los particulares **tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas** correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, **siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos** salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.

La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso administrativo de los actos o disposiciones administrativas no presupone, por sí misma, derecho a la indemnización.

- En todo caso, el **daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas**.

Asimismo, los particulares **tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos** como consecuencia de la aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos que no tengan el deber jurídico de soportar cuando así se establezca en los propios actos legislativos y en los términos que en ellos se especifiquen.

La responsabilidad del Estado legislador podrá surgir también en los **siguientes supuestos**, siempre que concurran los requisitos previstos en los apartados anteriores:

a) Cuando los daños deriven de la **aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional**.

Si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional, procederá su indemnización cuando el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada.

b) Cuando los daños deriven de la **aplicación de una norma contraria al Derecho de la Unión Europea.**

Si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma declarada contraria al Derecho de la Unión Europea, procederá su indemnización cuando el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la infracción del Derecho de la Unión Europea posteriormente declarada. Asimismo, deberán cumplirse todos los requisitos siguientes:

a) La norma ha de tener por objeto conferir derechos a los particulares.

b) El incumplimiento ha de estar suficientemente caracterizado.

c) Ha de existir una relación de causalidad directa entre el incumplimiento de la obligación impuesta a la Administración responsable por el Derecho de la Unión Europea y el daño sufrido por los particulares.

La sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o declare el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea producirá efectos desde la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o en el «Diario Oficial de la Unión Europea», según el caso, salvo que en ella se establezca otra cosa.

La responsabilidad patrimonial del Estado por el **funcionamiento de la Administración de Justicia** se regirá por la **Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial**.

El Consejo de Ministros fijará el importe de las indemnizaciones que proceda abonar cuando el Tribunal Constitucional haya declarado, a instancia de parte interesada, la existencia de un funcionamiento anormal en la tramitación de los recursos de amparo o de las cuestiones de inconstitucionalidad. El procedimiento para fijar el importe de las indemnizaciones se tramitará por el Ministerio de Justicia, con audiencia al Consejo de Estado.

Se seguirá el procedimiento previsto en la **Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas** para determinar la **responsabilidad de las Administraciones Públicas por los daños y perjuicios causados a terceros durante la ejecución de contratos cuando sean consecuencia de una orden inmediata y directa de la Administración o de los vicios del proyecto elaborado por ella misma** sin perjuicio de las especialidades que, en su caso establezca el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

3.1.2.- RESPONSABILIDAD CONCURRENTE DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

Cuando de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre **varias Administraciones públicas** se derive responsabilidad en los términos previstos en la presente Ley, las Administraciones intervinientes **responderán frente al particular, en todo caso, de forma solidaria**. El instrumento jurídico regulador de la actuación conjunta podrá determinar la distribución de la responsabilidad entre las diferentes Administraciones públicas.

En otros supuestos de concurrencia de varias Administraciones en la producción del daño, la responsabilidad se fijará para cada Administración atendiendo a los **criterios de competencia, interés público tutelado e intensidad de la intervención.** La responsabilidad será solidaria cuando no sea posible dicha determinación.

En los casos previstos en el apartado primero, la Administración competente para incoar, instruir y resolver los procedimientos en los que exista una responsabilidad concurrente de varias Administraciones Públicas, será la fijada en los Estatutos o reglas de la organización colegiada. En su defecto, la competencia vendrá atribuida a la Administración Pública con mayor participación en la financiación del servicio.

Cuando se trate de procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial, la Administración Pública competente a la que se refiere el apartado anterior, deberá consultar a las restantes Administraciones implicadas para que, en el plazo de quince días, éstas puedan exponer cuanto consideren procedente.

3.1.3.- INDEMNIZACIÓN.

Sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. No serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos, todo ello sin perjuicio de las prestaciones asistenciales o económicas que las leyes puedan establecer para estos casos.

En los casos de responsabilidad patrimonial a los que se refiere los apartados 4 y 5 del artículo 32, serán indemnizables los daños producidos en el plazo de los cinco años anteriores a la fecha de la publicación de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea, salvo que la sentencia disponga otra cosa.

La indemnización se calculará con arreglo a los **criterios de valoración establecidos en la legislación fiscal, de expropiación forzosa y demás normas aplicables**, ponderándose, en su caso, las valoraciones predominantes en el mercado. En los casos de muerte o lesiones corporales se podrá tomar como referencia la valoración incluida en los baremos de la normativa vigente en materia de Seguros obligatorios y de la Seguridad Social.

La cuantía de la indemnización se calculará **con referencia al día en que la lesión efectivamente se produjo**, sin perjuicio de su actualización a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad con arreglo al Índice de Garantía de la Competitividad, fijado por el Instituto Nacional de Estadística, y de los intereses que procedan por demora en el pago de la indemnización fijada.

La indemnización procedente podrá sustituirse por **una compensación en especie o ser abonada mediante pagos periódicos,** cuando resulte más adecuado para lograr la reparación debida y convenga al interés público, siempre que exista acuerdo con el interesado.

3.1.4.- RESPONSABILIDAD DE DERECHO PRIVADO.

Cuando las Administraciones Públicas actúen, directamente o a través de una entidad de derecho privado, en relaciones de esta naturaleza, su responsabilidad, incluso cuando concurra con sujetos de derecho privado o la responsabilidad se exija directamente a la entidad de derecho privado a través de la cual actúe la Administración o a la entidad que cubra su responsabilidad.

3.2.- RESPONSABILIDAD DE LAS AUTORIDADES Y PERSONAL AL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

3.2.1.- EXIGENCIA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LAS AUTORIDADES Y PERSONAL AL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

Para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial a que se refiere esta Ley, **los particulares exigirán directamente a la Administración Pública correspondiente las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por las autoridades y personal a su servicio.**

La Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, **exigirá de oficio en vía administrativa de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad** en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves, previa instrucción del correspondiente procedimiento.

Para la exigencia de dicha responsabilidad y, en su caso, para su cuantificación, se ponderarán, entre otros, los siguientes **criterios**: el resultado dañoso producido, el grado de culpabilidad, la responsabilidad profesional del personal al servicio de las Administraciones públicas y su relación con la producción del resultado dañoso.

Asimismo, la Administración instruirá igual procedimiento a las autoridades y demás personal a su servicio por los daños y perjuicios causados en sus bienes o derechos cuando hubiera concurrido dolo, o culpa o negligencia graves.

El procedimiento para la exigencia de la responsabilidad se sustanciará conforme a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y se iniciará por acuerdo del órgano competente que se notificará a los interesados y que constará, al menos, de los siguientes **trámites:**

a) Alegaciones durante un plazo de quince días.

b) Práctica de las pruebas admitidas y cualesquiera otras que el órgano competente estime oportunas durante un plazo de quince días.

c) Audiencia durante un plazo de diez días.

d) Formulación de la propuesta de resolución en un plazo de cinco días a contar desde la finalización del trámite de audiencia.

e) Resolución por el órgano competente en el plazo de cinco días.

La resolución declaratoria de responsabilidad pondrá fin a la vía administrativa.

Lo dispuesto en los apartados anteriores, se entenderá sin perjuicio de pasar, si procede, el tanto de culpa a **los Tribunales competentes**.

3.2.2.- RESPONSABILIDAD PENAL.

La **responsabilidad penal** del personal al servicio de las Administraciones Públicas, así como la **responsabilidad civil derivada del delito** se exigirá de acuerdo con lo previsto en la legislación correspondiente.

La exigencia de responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones Públicas **no suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan**, salvo que la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijación de la responsabilidad patrimonial.



. Ley 40/2.015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10566